

1500174-65.2020.8.26.0120

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... anônimas, fuga do suspeito e antecedentes no tráfico não são suficientes para o ingresso no domicílio.

Vejam os:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

1ª Vara

Praça Antonio Pípolo, s/nº, Candido Mota-SP - cep 19880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500174-65.2020.8.26.0120 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500174-65.2020.8.26.0120

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2135690/2020 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA, 11718048 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA, 425/20/104 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA, 2135690 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDGAR ALVES BICA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face EDGAR ALVES BICA, qualificado nos autos, como incurso nas condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Segundo a denúncia, em data de 03 de junho de 2020, por volta das 16h, na Rua São Judas Tadeu, n.º 293, nesta cidade e comarca de Cândido Mota, o acusado, teria guardado drogas, consistentes em 02 (dois) "eppendorff's" de cocaína, com massa líquida de 1,38 g (um grama e trezentos e oitenta miligramas), 01(uma) porção de cocaína, com massa líquida de 23,69 g (vinte e três gramas e seiscentos e noventa miligramas), e 01 (uma) porção de crack, com

massa líquida de 52,66 g (cinquenta e dois gramas e sessenta e seis miligramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 31,05 g (trinta e um gramas e cinquenta miligramas), as três últimas ainda não fracionadas, destinados ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Houve a notificação do réu (fl. 269), apresentou defesa prévia (fls. 264/266), e oportunamente houve o recebimento da denúncia (fls. 274/276).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e o denunciado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, aduzindo que os fatos foram plenamente demonstrados em juízo. A defesa, por sua vez, após tecer considerações sobre as provas produzidas em juízo, pugnou pela absolvição do acusado, afirmando inexistirem elementos suficientes para um decreto condenatório.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Dessa forma, primeiramente, cumpre ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, no qual estão delineadas as funções de acusar, defender e julgar, o que, por consentâneo, traduz-se durante a persecução penal uma distribuição lógica do ônus da prova, de acordo com os interesses imperativos de cada parte.

Na esteira da melhor doutrina, caberá à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Conquanto à defesa, a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena que tenha alegado.

No que se refere aos efeitos da produção da prova, direcionados ao magistrado, caberá ao Ministério Público a produção de provas que concretizem um juízo de certeza, enquanto à defesa, basta a produção de um cenário de dúvida ao julgador. Nesse sentido:

"Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual alibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova: para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável; para a defesa, basta criar um estado de dúvida. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 574.)"

Pois bem.

A pretensão punitiva deve ser julgada improcedente, vez que as preliminares de nulidade de ingresso ao domicílio suscitadas pelas defesas devem ser acolhidas, conforme adiante será fundamentado.

Vejamos as provas orais colhidas:

Ouvida em juízo a testemunha de acusação Erlon Dutra Pereira, policial militar, relatou que na data dos fatos estavam no batalhão de operações especiais. Foram solicitados para irem a Cândido Mota para fazer patrulhamento de roubos que estavam ocorrendo na cidade. Colheram informações de que no endereço do Edgar teriam produtos de roubo que teria ocorrido em Cândido Mota, informações de que a residência seria o ponto de encontro dos meliantes. Foram no local, na Rua avistaram ele saindo no local, quase na calçada. Quando ele avistou a viatura ele correu em um corredor e dispensou uns eppendorfs de cocaína. Em busca pessoal com ele não foi localizado nada. Na residência havia uma mulher, chamada de Kathlen,

ela foi solicitada a sair da residência. Com ela foi localizado cocaína. Essa mulher declarou que a cocaína era do Edgar. Um aparelho celular que ela estava em mãos ela declarava que era produto de roubo. Fizeram pesquisas nos sistemas e esse aparelho não constava como produto de roubo. Ela e o Edgar foram conduzidos para a delegacia. Foi solicitado o Canil, foi localizado uma mochila com entorpecentes. Não conhecia o Edgar. Atuam em Presidente Venceslau. Essa mochila estava dentro da residência, mas não se recorda o local. Também foi localizado um aparelho de som de um veículo. Visualizaram o Edgar no corredor, saindo na calçada, quando ele avistou a viatura e correu. Havia um banheiro no final do corredor. Até então não conheciam o Edgar. A atitude e as informações deram causa à abordagem. A afirmação que tinham era dos produtos de furto. O Edgar autorizou a entrada, ele dizia que poderia entrar que não tinha nada. A casa era dele, ele declarou que era dele. As informações foram dadas por policiais e populares.

Ouvida em juízo a testemunha de acusação Jose Marin Gonçalves Filho, relatou que na data dos fatos foram para Candido Mota, com informação de ocorrência de vários furtos na região. Esqueceu o nome do réu. Não se recorda bem dos fatos. Se recorda de terem recebido informações de que existiam produtos de furto. Estavam fazendo patrulhamento. Chegaram a entrar na residência. Não se recorda quem encontrou as drogas. Pelo que se recorda tinha pino de cocaína na bolsa da mulher, ele havia dispensado alguns na privada e confessou que havia feito isso. Ele teria dito que foi para uso próprio. A mulher se dizia namorada dele. O local era residência do Edgar. Não se recorda se foi chamado o canil. Tinham muitas operações na época. Fizeram várias ocorrências em Cândido Mota e Assis. Faziam parte do BAEP. Ele foi abordado fora da residência. Ele autorizou a entrada. Estava somente ele e a mulher no local. Não conhecia antes, o depoente não conhecia a cidade.

Ao final, em seu interrogatório judicial, o denunciado Edgar Alves Bica, relatou que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros. Um pino e meio, eram dois pinos, metade já havia usado. A menina que estava na casa era amiga da esposa do depoente. A mulher deu dinheiro para o depoente comprar entorpecentes para consumirem. A pessoa na casa era amiga da mulher do depoente. O depoente comprou três pinos, consumiram metade de um pino. O depoente escutou alguém passando no corredor sem falar nada, o depoente então correu no banheiro e jogou a capsula fora. O depoente é usuário crônico de cocaína. O depoente cheirava e jogava os pinos fora. O depoente foi na reta da porta para não estourarem a porta. Quando abriu a porta o policial estourou a porta, encostou o depoente em um canto, perguntou quem morava na casa, quem era o dono da casa. O depoente falava que era ele, os policiais diziam que era um tal de Macalé que morava na casa. Eles perguntaram de arma de fogo, mas não tinha arma. Bateram no depoente pedindo arma de fogo. Afogaram o depoente em um tanque de água. Tinha um outro policial que não prestou depoimento. Um dos policiais falou que enfiaria um cabo de vassoura na bunda do depoente caso não falasse onde estaria a arma de fogo. Um policial menor, "abençoado por Deus", falou para os outros pararem de bater no depoente. Pegaram uma gravação de uma outra pessoa falando que o depoente estava roubando. Pediram para entregar a arma, mas o depoente falava que não tinha arma. O depoente falou que tinha passagens anteriores por assalto que havia feito, o depoente assumiu o crime na época. O segundo fato tirou três anos em Londrina, por conta de um assalto. O depoente sempre confessou a prática. O depoente foi pego dentro de casa. Não tem banheiro no final do corredor. Na casa do depoente não tem terreno, é um corredor. Invadiram a casa do depoente sem mandado e sem autorização. O depoente não deu autorização para entrada. As outras drogas da denúncia não tinham. Não se recorda se eram dois ou três pinos. O depoente fala que não tem digital na droga que foi apreendida. Estava na Kethelyn na casa. Não se recorda se ela tinha bolsa ou mochila. Não tinha bolsa. O depoente não conhecia os policiais da BAEP, só conhecia a fama deles. Tem muita falha da polícia, isso foi uma prisão irregular, entraram sem mandado e não era droga do depoente. Já errou no passado, mas já pagou pelo passado, agora quer oportunidade para não ser condenado.

Pois bem.

A despeito das provas orais colhidas em juízo, bem como dos demais elementos de informação constante dos autos, é o caso de improcedência da ação penal em razão da

ilicitude da prova colhida decorrente da ilegalidade na violação do domicílio do acusado.

Com efeito, conforme dispõe o art. 5º XI da CF/88: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

De acordo com a Constituição Federal, portanto, a entrada em domicílio é permitida nas seguintes hipóteses disjuntivas: a) existir autorização judicial; b) consentimento válido e inequívoco do morador; c) houver fundadas e concretas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no local.

Tendo isso em vista, e com o máximo respeito aos posicionamentos jurídicos em contrário, entendo que nenhuma das referidas hipóteses estava presente no caso em tela.

No que tange à primeira hipótese que autorizaria a entrada da equipe policial em domicílio, referente à autorização judicial, sua ausência é incontroversa.

A segunda hipótese autorizativa, correspondente à autorização dos moradores para entrada da equipe policial no local, também não se afigura presente.

Trata-se de hipótese ainda carente de maior definição e regulamentação doutrinária e jurisprudencial, notadamente pela ausência de regulamentação legal dos requisitos de sua validade. Ou seja, não há no ordenamento jurídico regulamentação que indique a forma em que tal consentimento deve ser exarado, se verbal, por escrito, etc.

Dessa forma, na jurisprudência dos tribunais superiores tal questão não havia, minuciosamente, sido enfrentada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça visitou o tema em alguns julgados:

“(…) No ponto, registro que a denúncia anônima não foi minimamente esclarecida nos autos pelos agentes públicos policiais e a suposta autorização para ingresso no imóvel, embora confirmada pela tia do réu, não é válida, tampouco concede licitude à ação policial, pois se trata de pessoa com desconhecimento da lei, desassistida de profissional da área jurídica, hipossuficiente frente ao aparato policial (DENARC) que, por si só, exerce coação com a mera presença e, portanto, compreensível que a tia do réu tenha lhes autorizado a entrada no imóvel sem o conhecimento acerca da inviolabilidade do domicílio que lhe assiste na condição de residente. (STJ - HC: 423653 RS 2017/0288292-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)”

Mais recentemente, em julgamento paradigma no HC nº 598.051/SP, datado de 02 de Março de 2021, o Ministro Rogério Schietti analisou de maneira densa a questão, concluindo da seguinte maneira:

“3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.”

Consigno, por oportuno, que no que atine ao último trecho do julgado, em especial quanto à necessidade de registro em áudio e vídeo, tal ponto restou, posteriormente, anulado pelo Excelso Pretório, conforme julgamento do RE 1.342.077. Todavia, entendo que, a despeito de tal anulação, mantêm-se hígidos os demais fundamentos do acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto ao ônus da prova do Estado em demonstrar a inequívoca autorização do morador quanto ao ingresso dos agentes em seu domicílio, tal como, por exemplo, através declaração e autorização escrita.

Nessa toada, no caso concreto, embora haja menção nos depoimentos prestados em juízo pelas autoridades responsáveis pela prisão do denunciado no sentido de que este teria franqueado a entrada da equipe no domicílio, certo é que tal versão não encontra amparo nos autos.

Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, no que atine ao ingresso em domicílio do acusado, são contraditórios entre si, bem como com a versão apresentada durante a investigação policial.

Em solo policial, os agentes narraram que "(...) estavam verificando ocorrências de roubo na cidade de Cândido Mota-SP, e colheram informações de que no local dos fatos, endereço de Edgar Alves Bica, encontrariam produtos de roubo. O depoente e o policial José Marin foram até o endereço, sendo que quando Edgar viu a viatura policial correu para o banheiro, onde segundo o próprio Edgar, teria "dispensado" eppendorfs vazios. O depoente realizou uma revista pessoal em Edgar, sendo que com ele nada foi localizado. (...) " (fls. 17/18).

Denota-se, pois, que em um primeiro momento sequer houve menção quanto à autorização de entrada do morador no domicílio, invocando-se, em verdade, que o ingresso ocorreu por fundadas suspeitas pela prática de crime no local, o que será analisado oportunamente.

Em juízo, todavia, as versões são conflitantes.

Em seu depoimento, o policial Erlon Dutra Pereira relatou em um primeiro momento que, após receberem informações de que no local existiriam produtos de roubos ocorrido no município, deslocaram-se ao endereço e visualizaram o Edgar no corredor, saindo na calçada, quando ele avistou a viatura e correu e que a atitude e as informações deram causa à abordagem. Após, Erlon relata que o acusado teria franqueado a entrada da equipe no domicílio.

Por sua vez, o policial José Marin Gonçalves Filho relata em juízo que o acusado foi abordado fora da residência e autorizou a entrada, embora também relate que não se recorda muito bem dos fatos ocorridos.

Verifica-se que há contradição quanto à abordagem realizada e ausência de informações concretas quanto à forma em que ocorreu a operação, notadamente quanto ao ingresso do domicílio do acusado. Uma das testemunhas afirma que o acusado teria corrido para dentro da residência e, após, teria sido o denunciado abordado, situação na qual se presume, pois, que foi capturado dentro da residência. Após, em um segundo depoimento, há a afirmação de que o acusado foi abordado fora da residência e teria franqueado a entrada, o que diverge da primeira afirmação. Tais elementos, aliados à ausência de qualquer registro formal de autorização e franqueamento de ingresso ao domicílio, afastam a existência da hipótese de consentimento do morador para ingresso no local, o qual não pode, conforme já fundamento, ser reputado válido.

Resta, agora, analisar se no caso concreto se afiguravam presentes as fundadas razões para o ingresso das autoridades no domicílio do acusado.

E, in casu, a resposta é negativa.

A questão relativa aos contornos referentes às fundadas razões que autorizassem a entrada em buscas domiciliares sem mandado foi objeto de tese de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.616.

Na tese firmada ficou assentado que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"

No referido julgado, o Ministro Relator aponta, quando da fundamentação de seu voto, os contornos do que seriam as fundadas razões: " (...) A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal afirma sem ressalvas que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem a autorização de seu dono, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente. Pretendo demonstrar que essa tese esvazia a inviolabilidade domiciliar, contrariando a interpretação sistemática da própria Constituição e tratados de direitos humanos dos quais o país é signatário. Por isso, proporei evolução do entendimento".

Tem-se, inicialmente, a conclusão de que mesmo se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, considerado crime de natureza permanente, cuja consumação protraí-se no tempo, tal fato, de per si, não justifica a entrada em domicílio sem o competente mandado, o que correspondia ao entendimento, agora superado, do Excelso Pretório.

Em sequência, ao analisar quais seriam os elementos que poderiam ser considerados como justa causa a afastar a garantia de inviolabilidade de domicílio, o Ministro Relator do referido julgado aponta: "Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio. No entanto, ao ouvir gritos de socorro e ruídos característicos de uma briga vindos de dentro de uma residência, o policial tem fundadas razões para crer que algum crime está em andamento no ambiente doméstico. Não se deve exigir que busque confirmação adicional para agir. Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa". Após tal julgamento paradigma certo é, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado, à luz da ratio decidendi do acórdão anteriormente mencionado, posicionamentos semelhantes tentando tornar palpável o que seriam as "fundadas razões" a fim de evitar a concessão de salvo conduto para que as autoridades ingressem em qualquer residência à procura de drogas em verdadeiras "fishing expeditions".

Atualmente é entendimento pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça o fato de que denúncias anônimas, fuga do suspeito e antecedentes no tráfico não são suficientes para o ingresso no domicílio.

Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS DELA DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protraí-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida. 3. A prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP. (REsp 1871856/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) (destacou-se). (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui jurisprudência no sentido de que "A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si só, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial" (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020) "

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL E SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. Ainda que esta Sexta Turma tenha admitido como fundamento para a prisão preventiva a relevante quantidade entorpecentes apreendidos em poder da paciente, tratando-se de 132 pedras de crack, 84 papélotes de cocaína e ainda 26 trouxinhas de maconha, não foi apontado nenhum elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência da paciente, citando-se apenas a verificação de denúncias de tráfico de drogas que receberam através do "Disque Denúncia", e a fuga do adolescente.
2. Verifica-se ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio,

determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, quando não há referência a prévia investigação policial para verificar a possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e robustas acerca da traficância no domicílio violado. (STJ, Sexta Turma, RHC 83.501/SP, Rel. Mini. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018)"

"(...) Somente a informação de que o paciente tivera envolvimento anterior com tráfico de drogas não autoriza a autoridade policial a conduzi-lo até seu local de trabalho e sua residência, locais protegidos pela garantia constitucional do art. 5º, IX, da CF, para ali efetuar busca, sem prévia autorização judicial e sem seu consentimento, diante da inexistência de fundamento suficiente para levar à conclusão de que, naqueles locais, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Precedente: (HC 527.161/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) "

Dessa forma, as denúncias anônimas não podem ser suficientes para embasar imediatamente medidas invasivas, mas tão somente para dar início a diligências preliminares de averiguação, tais como campanas, por exemplo. A partir daí, verificada e constatada a ocorrência da prática delituitosa, tal como, por exemplo, quando a equipe policial, ao realizar campana, verifica atividades de transações de drogas defronte ou no interior de uma residência, teriam por configuradas as fundadas razões autorizando a entrada da equipe.

No caso em tela, todavia, não é o que se verifica.

Embora, de fato, os policiais tenham mencionado que receberam informações de que no local de residência do acusado existiriam produtos decorrentes da prática de crime - furtos e roubos - certo é que, pelos depoimentos constantes dos autos em juízo, não ocorreram, pelas autoridades que realizaram a prisão em flagrante, qualquer diligência prévia para atestar a veracidade das informações, mas sim o ingresso direto no domicílio da pessoa suspeita, o que se afigura irregular.

Diante das informações anônimas recebidas, preferiram, pois, realizar o ingresso imediato no domicílio no local indicado, sem qualquer diligência formal ou prévia anterior, tal como a realização de campanas ou, ainda, o encaminhamento de tais informações à Autoridade Policial do município, diante das quais, após a instauração de investigação, poderia angariar elementos para, então, realizar o pedido de busca e apreensão no local.

Dessa forma, conforme já salientado, tem-se por combativa, atualmente, a Jurisprudência dos Tribunais Superiores no que tange às denominadas fishing expeditions a fim de se coibir a cifra oculta de casos em que - mesmo evidenciada a boa-fé das autoridades policiais - domicílios tenham sido adentrados, privacidades violadas e, ao fim, teria sido infrutífera a diligência, em razão da inexistência de ilícito no local. Em situações tais, dificilmente haveria conhecimento de tal situação, justamente porque nada de ilícito foi encontrado e nenhum procedimento formal instaurado.

Tal entendimento, mais restritivo, visa coibir que pessoas inocentes tenham suas residências invadidas pelas autoridades estatais sem que haja, minimamente, razões suficientes a autorizar a mitigação da proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar. Ainda, tratando-se de garantia fundamental, aplica-se a todos os indivíduos, não sendo possível valer, ainda, a lógica utilitarista de que os fins justificam os meios, ou seja, que uma vez encontrado o entorpecente, tornaria lícita, ao final, a quebra da garantia constitucional.

Essa é a razão fundamental de a Constituição atribuir, via de regra, ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional e, como característica inerente, imparcial, a atribuição de analisar os elementos trazidos pelas autoridades a fim de se averiguar se é possível ou não relativizar a inviolabilidade domiciliar.

O voto-vista do Ministro Rogério Schietti Cruz no RHC 83501/SP bem esclarece a situação: "Não se há de admitir, portanto, que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz (um "terceiro neutro e desinteressado") só pode determinar a busca e apreensão durante

o dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente."

Consigno, ainda, que eventualmente o fato de o portão da residência encontrar-se aberto também não basta para o ingresso na residência, pois não retira a inviolabilidade do domicílio.

Vejamos trecho elucidativo do voto do Ministro Nefi Cordeiro no recente julgamento do RHC 83.501/SP:

"Verifica-se, então, pelos depoimentos dos policiais, ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, pois, como destacado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no voto-vista, não há referência a prévia investigação policial para verificar a possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e robustas acerca da traficância naquele local, e acrescenta-se que o fato do portão da residência encontrar-se aberto não justifica a entrada dos policiais sem autorização judicial.

Nessa toada, pelo contexto fático delineado nos autos, em que pese a manifesta boa-fé das autoridades responsáveis pela apreensão, não havia elementos concretos que justificassem a invasão de domicílio sem a prévia autorização judicial, já que: não há prova de que houve consentimento válido e inequívoco do morador, o ingresso se baseou apenas em denúncias anônimas, circunstâncias essas que não eram capazes de caracterizar as fundadas suspeitas da prática delituosa dentro da residência a fim de autorizar a entrada no local.

Em situação semelhante, já decidiu também o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em julgado decorrente de feito que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Assis-SP:

"Tráfico - recurso da Acusação que não se conformou com a declaração da ilicitude da prova, obtida com violação ao domicílio, culminando na absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - impossibilidade de reforma para condenar o réu - As provas colhidas demonstram, de forma satisfatória, que a apreensão das substâncias entorpecentes ocorreu após invasão ao domicílio, sem autorização judicial ou dos moradores. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000198-19.2018.8.26.0580; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)"

Em razão do exposto, não estando presentes as situações que autorizavam o ingresso na residência do réu, certo é que houve ilicitude na obtenção da prova e, em razão disso, todas as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada - art. 157, §1º, CPP).

Nessa toada, dada a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, positivada no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, todas as demais provas encontram-se contaminadas pela ilicitude do marco zero, o que impõe a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para fins de ABSOLVER o denunciado EDGAR ALVES BICA, qualificados nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ficam revogadas eventuais medidas cautelares fixadas e prisões preventivas decretadas, expedindo-se o necessário, inclusive alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado proceda-se a devolução dos valores e bens lícitos apreendidos.

Caso ainda não tenha sido assim procedido, destrua-se o entorpecente apreendido na forma do art. 50, §3º, da Lei n. 11.343/06.

Expeça-se o necessário, realizando-se as comunicações de praxe.

Ciência ao MP.

PIC.

Candido Mota, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA